

1500203-52.2021.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/08/2022

... e robustas para sua condenação no tráfico de drogas, e seja absolvido do delito de associação ao tráfico e, não sendo desclassificado, aplique a pena do delito de tráfico de drogas no mínimo legal.

A defesa da ré Daiane Oliveira da Rosa, em memoriais (fls. 336/375), requer, o reconhecimento da: i - ilicitude da busca e apreensão procedida, uma vez, que oriunda de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí

Foro de Pirajuí

1ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí - SP - cep 16600-000

1500203-52.2021.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500203-52.2021.8.26.0453

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAIANE OLIVEIRA DA ROSA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de DAIANE OLIVEIRA DA ROSA, qualificada (fls. 95/96), e VALTER HENRIQUE BINI GOMES, qualificado (fls. 92/94), como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, porque em tese, no dia 10 de julho de 2020, às 06h40min, na Rua São João, nº 40, Centro, na cidade de Reginópolis e comarca de Pirajuí, guardavam e mantinham em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido total de 1,21g (uma grama e vinte e um centigramas), tratando-se de droga destinada ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia (fls. 125/128): Segundo o apurado, os denunciados se associaram previamente e se dedicavam à traficância e ao comer ilegal na cidade. Assim, policiais civis, com apoio da polícia militar e de cão farejador, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido por essa Vara Judicial, nos autos do Processo nº 1500266-14.2020, dirigiram-se até a casa dos denunciados.

Em buscas no imóvel, foi encontrado, em cima da geladeira, junto a uma cédula de R\$ 10,00 (dez reais), uma porção de maconha, com peso líquido de R\$ 1,21g (uma grama e vinte e um centigramas). Ainda, na janela da cozinha, foi encontrado um cigarro artesanal com a mesma substância entorpecente e, sobre a pia, um dichavador com resquícios de maconha.

Prosseguindo nas buscas, foi encontrado sobre o guarda-roupas do quarto do casal, no interior de um pé de tênis, o valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), em notas variadas, bem como um pedaço de papel com manuscritos referentes à anotações do tráfico, com nomes e valores.

Regularmente notificados (fl. 145), o réu Valter Henrique apresentou defesa prévia por seu defensor dativo (fls. 153/159), assim também fazendo a ré Daiane Oliveira Rosa (fls. 168/182).

Recebida a denúncia em 07 de janeiro de 2022 e não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento nesta comarca (fls. 189/191).

A ré Daiane de Oliveira da Rosa opôs embargos de declaração (fls. 207/213), a fim de sanar a omissão da r.Decisão de fls. 189/191, que recebeu a peça acusatória, exarando-se juízo explicito de delibação das matérias arguidas por ambas as defesas dos corréus em sede de defesa preliminar.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 219/222, pela rejeição dos embargos de declaração apresentados pela defesa, visto que não há qualquer omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade a ser sanada.

Conforme decisão de fls. 227/231, foram mantidas as determinações de fls. 189/191, inclusive a designação da audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas da acusação PM Leandro Ramos da Silva e PM Plínio Luna Gonçalves, sendo os réus interrogados ao final.

O Ministério Público, em memoriais (fls. 312/318), pugnou pela procedência da ação, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas descritas na denúncia.

Por seu turno, a defesa do réu Valter Henrique Bini Gomes, em memoriais (fls. 326/335), requer a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06, pois comprova-se nos autos a dependência química do acusado, sendo que não há também provas suficientes e robustas para sua condenação no tráfico de drogas, e seja absolvido do delito de associação ao tráfico e, não sendo desclassificado, aplique a pena do delito de tráfico de drogas no mínimo legal.

A defesa da ré Daiane Oliveira da Rosa, em memoriais (fls. 336/375), requer, o reconhecimento da: i - ilicitude da busca e apreensão procedida, uma vez, que oriunda de representação policial que se fundamenta apenas na existência de denúncias anônimas; ii - ilicitude da apreensão do celular de pessoa estranha ao objeto da busca domiciliar, e sequer figurava como investigada; iii - ilicitude da violação do sigilo das comunicações do celular de Daiane, sem autorização prévia e específica para o tanto. Caso as questões anteriores não sejam acolhidas, requer sua absolvição quando as delitos tipificados no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Em caso de sentença condenatória, que seja concedido à corré o direito de recorrer em liberdade, bem como seja restituído o aparelho celular da marca Samsung à acusada. É o relatório.

#### FUNDAMENTO.

De início, afasto a alegação da nulidade da busca e apreensão. No caso, não se pode falar em busca e apreensão derivada apenas de notícia anônima. Conforme bem fundamentado na decisão de fls. 14/15 dos autos nº 1500266-14.2020.8.26.0453, fundamentada no relatório apresentado pelo setor de investigação (fls. 03/08 daqueles autos), após o recebimento das denúncias anônimas, foram realizadas campanhas no local, "verificando considerável movimentação de pessoas no local mencionado, com características de ponta de venda de substância de entorpecentes ilícitas". Ademais, o depoimento dos policiais, em juízo, que atuaram no caso, corroboraram tal informação de que a busca foi precedida de outras investigações, desencadeadas a partir da notícia anônima, a exemplo de Leandro Ramos da Silva: "Que diante das denúncias, foram realizadas campanhas, sendo que em data posterior diligenciou juntamente com os policiais militares e cães farejadores, o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por esta Vara, com o intuito de apurar denúncias acerca de suposto comércio de entorpecentes no município mencionado .

Houve, portanto, outras diligências prévias, motivo pelo qual não se pode cogitar de nulidade. Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Posse ilegal de arma de fogo. Inquérito policial. Falta de justa causa para o processamento do inquérito. Nulidade da busca e apreensão. Quebra da cadeia de custódia. Excesso de prazo para a finalização das investigações. Liminar indeferida. (...). 3. Ausência de justa causa na ordem de busca e apreensão. Alegação afastada. Os procedimentos de busca e apreensão não se fundaram em denúncia anônima. Após o recebimento das informações apócrifas, a autoridade policial destacou equipe que permaneceu em campanha no local indicado. Colheita de elementos que sustentaram o quadro de verossimilhança das informações. Procedimento que encontra assento no campo da legalidade. Precedentes. 4. Pedido de concessão de salvo conduto. Meras conjecturas sobre eventual decretação de prisão cautelar que não revelam quadro de risco objetivo, atual ou iminente, à liberdade de locomoção. Precedentes. 5. Habeas Corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2029370-58.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021) – grifei.

Com relação à alegação de ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares em relação à ré Daiane, bem como a apreensão de seu celular, com extravio das mensagens, razão não assiste à Defesa.

Com efeito, não houve ilicitude no procedimento adotado pelos agentes policiais que, no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão anteriormente deferido por este juízo, apreenderam os objetos que tiveram relação com o fato, entre eles o aparelho celular da ré, além de colherem todas as provas que serviam para esclarecimento do delito e suas circunstâncias, verificando os registros de mensagens existentes no celular relacionadas à prática do narcotráfico.

De se ver que os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que a própria ré quem promoveu o desbloqueio do aparelho, o que não afastado a contento pela defesa. Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, afasta a alegação de nulidade. A propósito: "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova oriunda do acesso aos dados armazenados no aparelho celular, relativos a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos (Whatsapp), obtidos diretamente pela polícia no momento da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial. In caso, denota-se que os policiais acessaram as conversas telefônicas do aparelho celular do paciente sem autorização judicial, mas com a permissão do acusado, o que, de fato, não configuraria a ilegalidade" (HC 537.274/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) – grifei.

Além do mais, não se pode ignorar que a decisão que autorizou a busca e apreensão naquele feito (fls. 25/26 do Processo nº 1500266-14.2020.8.26.0453) permitiu o acesso ao conteúdo dos aparelhos eventualmente encontrados, ainda que tal linha investigativa, a princípio, limitar-se-ia ao corréu Valter.

Isso porque tal procedimento não ofende o princípio da serendipidade, observando-se que "Segundo a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. Assim, embora em um primeiro momento a investigação não tenha sido dirigida ao recorrente, o encontro fortuito de provas, ocorrido em procedimento efetuado com observância da legislação de regência (perícia na celular do corréu) é válido para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas" (STJ 117113/MG Quinta Turma RHC Rel. I. Min. Ribeiro Dantas j. 26.11.2019). – grifei.

Afastadas, portanto, as preliminares arguidas pela defesa, o feito encontra-se em

ordem.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, aos acusados.

Passo a análise da prova oral produzida.

O policial civil Leandro Ramos da Silva, em fase inquisitorial (fl. 22) relatou, que: "Na data dos fatos, visando dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela 1ª Vara Criminal de Pirajuí/SP, conforme os autos do processo digital nº 1500266-14.2020.8.26.0453, com o intuito de apurar denúncia acerca de suposto comércio de entorpecentes no município de Reginópolis, na presente data diligenciei juntamente com o apoio de policiais militares e ainda com o uso de cão farejador da polícia civil, até a residência dos então investigados Valter e Daiane, sendo que momentos antes eu me encontrava em outra residência próxima, também auxiliando em trabalhos de busca domiciliar; que ao adentrarmos então nesta segunda residência, cientificamos os investigados quanto ao motivo da nossa presença; que durante o procedimento de buscas na residência logrei êxito ao encontrar uma porção de erva seca aparentando ser o entorpecente conhecido como "maconha", a qual estava em cima da geladeira, junto a uma cédula de R\$10,00 (dez reais). Que na janela da cozinha, do lado externo do cômodo, localizei um cigarro artesanal contendo a mesma substância; que em prosseguimento às buscas, encontrei sobre o guarda-roupas do quarto do casal, no interior de um pé de tênis, o valor em espécie de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), juntamente com um pedaço de papel contendo manuscritos com nomes e valores; que ainda na cozinha, localizei sobre a pia, encontrei um objeto conhecido como "dichavador", contendo resquícios de erva aparentando ser maconha; que por fim, também foram encontrados na residência um telefone celular da marca samsung, de propriedade de Daiane Oliveira da Rosa, a qual efetuou de imediato o desbloqueio do aparelho, e um outro aparelho da marca LG, pertencente ao investigado Valter Henrique Bini Gomes, o qual não efetuou o desbloqueio, sob alegação de não saber a senha, e dizer que havia adquirido o mesmo há quatro dias."

Em juízo, o policial civil Leandro Ramos da Silva, relatou, que frequentemente a Delegacia recebia denúncias de que Valter teria se mudado para a cidade de Reginópolis, para morar com Daiane, no bairro Nova Conquista, e estariam realizando a prática de tráfico de Drogas. Que diante das denúncias, foram realizadas campanhas, sendo que em data posterior diligenciei juntamente com os policiais militares e cães farejadores, o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por esta Vara, com o intuito de apurar denúncias acerca de suposto comércio de entorpecentes no município mencionado. Aduz, que ao adentrar na residência dos réus, na cozinha, logrou com êxito ao encontrar uma porção de droga, já fracionada, junto a uma cédula de R\$ 10,00 (dez reais), que lado externo do cômodo localizou um cigarro artesanal contendo a mesma substância. Em continuidade as buscas, foi localizado em cima do guarda-roupas do quarto do casal, no interior de um sapato, uma quantia em dinheiro, juntamente com um pedaço de papel contendo manuscrito com nomes e valores. Ainda, na cozinha foi localizado sobre a pia tinha um dichavador". Por fim, relatou, que encontraram também um celular, de propriedade da ré, a qual efetuou de imediato o desbloqueio do aparelho, e um outro aparelho pertencente ao réu, o qual não efetuou o desbloqueio.

O policial militar Plínio Luna Gonçalves, em fase inquisitorial (fl. 23), declarou, que: "Na data dos fatos, visando dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela 1ª Vara Criminal de Pirajuí/SP, conforme os autos do processo digital nº 1500266-14 .2020.8.26.0453, com o intuito de apurar denúncia acerca de suposto comércio de entorpecentes no município de Reginópolis, na presente data prestei apoio à polícia civil de Reginópolis, em diligências na residência dos então investigados Valter e Daiane, sendo que momentos antes eu me encontrava em outra residência próxima, também auxiliando em trabalhos de busca domiciliar; que ao adentrarmos então nesta segunda residência, cientificamos os

investigados quanto ao motivo da nossa presença. Que durante o procedimento de buscas na residência, presenciei o momento em que o policial leandro logrou êxito ao encontrar uma porção de erva seca aparentando ser o entorpecente conhecido como "maconha", a qual estava em cima da geladeira, junto a uma cédula de R\$10,00 (dez reais). Que na janela da cozinha, do lado externo do cômodo, o referido policial localizou também um cigarro artesanal contendo a mesma substância e em prosseguimento às buscas, o policial leandro também encontrou sobre o guarda-roupas do quarto do casal, no interior de um pé de tênis, o valor em espécie de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), juntamente com um pedaço de papel contendo manuscritos com nomes e valores; que ainda na cozinha, o policial leandro localizou sobre a pia, um objeto conhecido como "dichavador", contendo resquícios de erva aparentando ser maconha; que por fim, também foram encontrados na residência um telefone celular da marca Samsung, de propriedade de Daiane Oliveira da Rosa, a qual efetuou de imediato o desbloqueio do aparelho, e um outro aparelho da marca LG, pertencente ao investigado Valter Henrique Bini Gomes, o qual não efetuou o desbloqueio, sob alegação de não saber a senha, e dizer que havia adquirido o mesmo há quatro dias."

Em juízo, o policial militar Plínio Luna Gonçalves, apresentou versão semelhante. Relatou, que na data dos fatos, diligenciou juntamente com os policiais militares e cães farejadores, o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por esta Vara, com o intuito de apurar denúncias acerca de suposto comércio de entorpecentes no município de Reginópolis. Aduz, que ao adentrar na residência dos réus logrou com êxito ao encontrar uma porção que aparentava ser entorpecente conhecido como "maconha", a qual estava em cima da geladeira, junto a uma cédula de R\$ 10,00 (dez reais), sendo que do lado externo do cômodo localizou um cigarro artesanal contendo a mesma substância, ainda, na cozinha foi localizado sobre a pia tinha um "dichavador". Em continuidade as buscas, foi localizado em cima do guarda-roupas do quarto do casal, no interior de um pé de tênis, o valor em espécie de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), juntamente com um pedaço de papel contendo manuscrito com nomes e valores.

Em fase inquisitorial, Valter Henrique Bini Gomes, declarou (fls. 92/94), que: "O entorpecente que estava na residência era de sua propriedade. Quanto ao "bilhete manuscrito", disse que tratava-se de anotações feitas por ele, voltadas ao serviço em que desempenhava na época, referente a metragem de madeiras, uma vez que descascava eucalipto, atividade que consistia na diferenciação de madeiras, sendo ainda, que o valor apreendido era referente a este serviço. Afirma, não saber do que se trata a expressão "do verde" e, por fim, quando o mesmo, refere-se a 100g de maconha que adquiriu no trevo de Reginópolis, diz ser para consumo, quantidade essa que iria dividir e dar metade para uma pessoa conhecida por "negão". Quanto ao "lucrinho que disse que iria depositar para um "mano", estava referindo-se à venda de cuecas que estava comercializando."

Interrogado em juízo, o réu, esclareceu que é usuário de "maconha", sendo que atualmente mora com sua esposa, que não é Daiane, e seus dois filhos. Afirma que o entorpecente que estava na residência era de sua propriedade, exclusivamente para seu uso e de Daiane, que também era usuária. Quanto ao "bilhete manuscrito", disse que tratava-se de anotações feitas por ele, voltadas ao serviço em que desempenhava na época, referente a metragem de madeiras, uma vez que descascava eucalipto, atividade que consistia na diferenciação de madeiras, sendo ainda que o valor apreendido era referente a este serviço. Em relação à afirmação dos policiais quanto ser conhecido nos meios policiais, diz ser sobre seu passado, pois já teria chegado na cidade de Reginópolis empregado.

Em fase inquisitorial Daiane Oliveira da Rosa, relatou (fls. 95/96), que : "As drogas localizadas era de seu companheiro na época dos fatos. Esclarece, que não tinha conhecimento da existência do dinheiro que foi localizado, nem tampouco do bilhete contendo anotações. Em conversas mantidas em aparelho celular, onde tal pessoa pede o "verde", ocasião, em que disse que iria separar, aduz, que o "verde" referia-se a "maconha" e quanto ao trecho que iria separar, não recorda-se do que se tratava. Por fim, afirmou, que as pessoas procuravam-os através de mensagens, para adquirir a substância entorpecente, sendo que disse para Valter que quando

terminasse de vender as substâncias que tinha, pediu para que o mesmo parasse com a venda de drogas."

Interrogada em juízo, a ré, relatou que atualmente reside com seu marido e seus três filhos. Em relação às drogas localizadas era de seu companheiro na época dos fatos. Quanto ao diálogo, com sua amiga com Daiane Pereira, bem como com Marceli, esclarece que fumavam juntas; em relação à mensagem de Daiane, a qual, constava que iria deixar separado, tratava-se de uma roupa, pois teria dito a mesma que não tinha maconha, sendo certo, que nunca vendeu droga.

Eis a prova produzida.

Encerrada a exposição da prova oral convém salientar que a ação penal é parcialmente procedente, a fim de condenar Daiane e Valter pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva quanto a este delito descrito na denúncia.

A existência material do crime de tráfico ficou comprovada, consoante se depreende do boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelas fotografias (fls. 09/19), pelos laudos definitivos de entorpecentes (fls. 27/31 e fls. 32/36) que detectaram a presença da substância THC (Tetrahidrocannabinol), pelos laudos dos aparelhos telefônicos (fls. 37/48), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, a condenação do réus é medida consequencial da prova existente nos autos.

Concluída a descrição da prova oral colhida ao longo da audiência de instrução, ressalto que a versão dos réus se revelou isolada nos autos.

Não há nos autos nenhum elemento que identifique a intenção dos policiais militares em prejudicá-los. Pelo contrário, o relato dos policiais guarda precisão com as demais provas colhidas.

Destaco que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, pois presente o réu e seu defensor, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o Estado conceder aos agentes de segurança pública crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada (STJ, 5ª Turma, HC nº 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Data do julgamento: 03/02/2009, Data da publicação: 09/03/2009).

APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa -

Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas -

Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ -

Potencialidade lesiva das munições constatada por laudo pericial - Necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12, "caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' - Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido (TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0001753-88.2018.8.26.0542, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do julgamento: 21/12/2020, Data da publicação 21/12/2020.)

Estabelecida tal premissa, saliento que, em seu interrogatório, o réu Valter confessou ser dependente químico, usuário de maconha, afirmando, portanto, que a droga encontrada era para uso de ambos os acusados. Por sua vez, a ré Daiane afirmou que a droga era de propriedade apenas do corréu, seu companheiro à época dos fatos.

Outrossim, é importante atentar-se para o fato de que as testemunhas policiais militares, que atenderam a ocorrência, narraram com riqueza de detalhes como se deu a apreensão da droga, sobretudo o encontro de dinheiro escondido em tênis, além do encontro de anotações.

Ademais, outros elementos que permitem concluir que os réus não apenas tinham em depósito drogas para consumo pessoal são as condições em que se desenvolveu a ação, como se observa das fotografias de fls. 09/91.

Isto é, embora a quantidade total de entorpecente apreendida até justificaria ser para consumo individual, é importante anotar a apreensão da importância de R\$175,00 (cento e setenta e cinco reais) em moeda corrente, fracionada em 2 (duas) notas de R\$50,00, 3 (três) notas de R\$20,00, 1 (uma) nota de R\$10,00, 2 (duas) notas de R\$ 2,00 (dois reais) e 1 (uma) moeda de R\$1,00, figura como mais um indício da prática do tráfico de drogas devido à sua compatibilidade com a venda de algumas porções e a presença de numerário apto a servir como troco de forma a facilitar a transação. Não bastasse, a maior quantia em dinheiro foi encontrada escondida, dentro de um tênis (fotografia de fls. 16), enquanto uma das notas se encontrava escondida dentro de uma vasilha (fotografia de fls. 19).

Vale registrar que, embora o réu afirme que o dinheiro seria fruto de seu trabalho, não trouxe nenhuma prova nesse sentido. Ou seja, verifica-se que o réu Valter não demonstrou a origem lícita do dinheiro, tendo sido o numerário apreendido nas mesmas circunstâncias fáticas de parte do entorpecente, o que demonstra sua relação com o comércio nefasto da droga.

Além disso, foi encontrada, também dentro do tênis, anotações referentes ao tráfico de drogas (fotografias de fls. 12 e 16), bem como mensagens trocadas entre réus, que evidenciam a prática do comércio ilícito de entorpecentes. Mais uma vez, neste ponto, a versão dos réus não encontra respaldo nas demais provas coligidas aos autos.

O réu Valter afirma que tais anotações se referiam ao seu trabalho no corte de eucalipto. Contudo, não junta, novamente, nenhuma prova neste sentido. Por outro lado, observa-se que uma das anotações se refere ao nome "Gaby", também referido nas mensagens trocadas entre os réus (fls. 55).

Em relação às mensagens trocadas, a versão dos réus também não se sustenta, pois, sem dúvida, refere-se à venda de maconha, intitulada de "verde".

Por todas estas razões, fica afastada, também, a desclassificação do delito em comento para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. O fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação. Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Na mesma esteira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "(...) muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário é sabido que nada impede que

possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente" (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

A propósito, está disposto no § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 as diretrizes que determinam se a droga destina-se a consumo pessoal, a saber: § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Em suma, há indícios em abundância (a denúncia anônima recebida pelos policiais, forma de acondicionamento dos entorpecentes, o dinheiro em espécie e notas variadas, as anotações e mensagens trocadas entre os réus) que, em conjunto, permitem concluir com segurança que as drogas guardadas e mantidas pelos acusados tinham por destino o tráfico, e não o consumo próprio.

- Art. 35, caput, da Lei de Drogas

Todavia, em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, as provas dos autos não se revelam suficiente para a condenação.

Concluída a descrição da prova oral coletada ao longo da audiência de instrução, observo que os depoimentos das testemunhas não possuem a certeza de que os réus, efetivamente, associaram-se para o tráfico de drogas.

Embora haja a conversa entre os réus que demonstre a venda, não há prova suficiente da estabilidade e permanência exigida para a condenação da associação.

Destaco que não há um nexo de continuidade temporal relevante entre as condutas, podendo ter sido atos esporádicos, o que afasta a tipicidade da associação para o tráfico.

Em outras palavras, a alegada associação entre os réus não restou provada a contento, pois o máximo que a prova dos autos permite divisar é a coautoria.

Enfatizando a questão, não há qualquer evidência de que os réus associaram-se para a prática do tráfico de drogas, com a necessária habitualidade que o tipo penal requer, inexistindo "prova da estabilidade ou permanência da associação", requisito tido pela doutrina como indispensável e que não se confunde com a eventualidade do tráfico (Nova Lei de Drogas Comentada, Coord. Luiz Flavio Gomes, Editora RT, 2006, págs. 170/171).

APELAÇÕES CRIMINAIS. 1. PRELIMINAR - Pedido para recorrer em liberdade -

Descabimento - Julgamento do mérito recursal substitui a decisão sobre o direito de recorrer em liberdade - Manutenção da cautelar de rigor - PRELIMINAR REJEITADA. 2.

RECURSO DEFENSIVO - Organização criminosa - Artigo 1º e 2º, da Lei 12.850/2013 -

Autoria e materialidade comprovadas - Investigações da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público em que se chegou a autoria do réu - Acusado que integrava o "Primeiro Comando da Capital" - Documentação atestando a "filiação" e "batismo" do réu ao PCC- Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena -

Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma adequada - Regime semiaberto - Adequado ao caso concreto, sobretudo diante do quantum da pena - APELO NÃO PROVIDO. 3.

RECURSO MINISTERIAL - Associação para o tráfico- Artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 - Decisão que absolveu o acusado quanto a este delito - Recurso ministerial

pleiteando a inversão do decisor - Ausência de provas de que, no bojo da organização criminosa, o acusado exercesse com estabilidade e permanência o delito de tráfico de drogas - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0012982-

61.2019.8.26.0590; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2021; Data de Registro: 24/10/2021

Isto é, em sede processual penal, diante do princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como do princípio do in dubio pro reo - o qual assegura, quando da valoração da prova, que na dúvida, o acusado deve ser absolvido - o grau ou nível de prova exigido (standard probatório) para a prolação de um decreto condenatório é bastante elevado, de modo que este deve ser baseado em provas além de qualquer dúvida razoável. Nesse sentido:



CRIME DO ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA ACIMA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. (...) 4. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo-saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt) e que foi consagrado" (STF, 1ª Turma, AP 580, Rel. Min. Rosa Weber, Data do julgamento: 13/12/2016, Data da publicação: 26/06/2017.). - grifei.

No presente caso, o conjunto probatório é extremamente frágil, por conseguinte, é medida imprescindível, para a consecução da justiça, a absolvição dos réus quanto ao delito de associação.

Constatada a tipicidade, ilicitude e culpabilidade do fato, passo a dosar a pena do crime, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Réu Valter

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não cabendo o agravamento da pena.

B) Antecedentes: Não há antecedentes (fls. 133/135). A condenação de fls. 133 será valorada na segunda etapa.

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu, não cabendo o agravamento da pena.

E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime não apresentam elementos que impliquem no aumento da pena.

G) Consequências do crime: Ausentes informações quanto às consequências do crime, não cabendo o agravamento da pena.

H) Comportamento da vítima: O crime não possui vítima determinada.

I) Natureza e quantidade da droga: Este juízo filia-se ao entendimento de que os requisitos do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade) são cumulativos. No caso, nem a quantidade das drogas apreendidas, nem a natureza das drogas apreendidas sob a posse do réu (maconha), justificam o aumento da pena.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda etapa

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 133: Processo nº 0001750-12.2018.8.26.0453). Desse modo, a exacerbação da pena se faz presente, diante da reincidência, razão pela qual majoro a pena em 1/6.

Da análise da circunstância agravante, fixo, na segunda fase, a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Terceira etapa

Não há causas de aumento da pena.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o referido dispositivo legal estabelece quatro requisitos cumulativos para que o réu possa fazer jus à causa de diminuição de pena: ser o agente primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê aplicação do redutor somente no caso de preenchimento cumulativo dos requisitos elencados, quais sejam, agente primário, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. É uma benesse cuja aplicação deve se dar somente nos casos em que, de fato, os requisitos estejam preenchidos sob pena de gerar impunidade.

No caso dos autos, as certidões juntadas evidenciam que se trata de acusado reincidente (fls. 133/135).

Assim, mantenho, na terceira fase, a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.  
Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, consoante o sistema trifásico de aplicação.  
Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, conforme artigo 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal, diante da reincidência do réu.  
Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu é reincidente e foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal)..  
Suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I, II e III, do Código Penal): Inadmissível, pois o réu é reincidente e foi condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos (artigo 77, caput, do Código Penal).  
Valor do dia-multa (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

Ré Daiane

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

- A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do insito ao tipo penal, não cabendo o agravamento da pena.
  - B) Antecedentes: Não há antecedentes (fls. 132).
  - C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social da ré, não cabendo o agravamento da pena.
  - D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade da ré, não cabendo o agravamento da pena.
  - E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.
  - F) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime não apresentam elementos que impliquem no aumento da pena.
  - G) Consequências do crime: Ausentes informações quanto às consequências do crime, não cabendo o agravamento da pena.
  - H) Comportamento da vítima: O crime não possui vítima determinada.
  - I) Natureza e quantidade da droga: Este juízo filia-se ao entendimento de que os requisitos do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade) são cumulativos. No caso, nem a quantidade das drogas apreendidas, nem a natureza das drogas apreendidas sob a posse da ré (maconha), justificam o aumento da pena.
- Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda etapa

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes..

Da análise da circunstância agravante, fixo, na segunda fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira etapa

Não há causas de aumento da pena.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o referido dispositivo legal estabelece quatro requisitos cumulativos para que o réu possa fazer jus à causa de diminuição de pena: ser o agente primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê aplicação do redutor somente no caso de preenchimento cumulativo dos requisitos elencados, quais sejam, agente primário, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. É uma benesse cuja aplicação deve se dar somente nos casos em que, de fato, os requisitos estejam preenchidos sob pena de gerar impunidade. No caso dos autos, embora as certidões juntadas evidenciam que se trata de acusada

primária, as mensagens trocadas entre os réus, ainda que não justifiquem, no entendimento desta juízo, uma condenação por associação, por certo demonstram a dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação do privilégio mencionado. Assim, mantenho, na terceira fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, consoante o sistema trifásico de aplicação. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Semiaberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal, diante do quantum da pena.

O pedido do Ministério Público de fixação de regime inicial fechado não deve prosperar visto que já houve declaração, em sede de controle difuso de constitucionalidade, da inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, por violação ao princípio da individualização da pena. Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que "[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado". Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (STF, Tribunal Pleno, HC 111.840/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli, Data do julgamento: 27/06/2012, Data da publicação: 17/12/2013).

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Incabível, afinal, a ré foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I, II e III, do Código Penal): Inadmissível, pois a ré foi condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos (artigo 77, caput, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006): Ausentes elementos de informação que demonstrem que a ré possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar os réus DAIANE OLIVEIRA DA ROSA e VALTER HENRIQUE BINI GOMES, já qualificados, por terem praticado fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 5

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, atribuído a cada dia-multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo federal vigente ao tempo do fato, em regime semiaberto (Daiane) e 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, atribuído a cada dia-multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo federal vigente ao tempo do fato, em regime fechado (Valter). Por sua vez, para absolver os réus, nos termos do art. 386, VII do CPP, quanto ao fato tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita (decisão de fls. 189/191).

Após o trânsito em julgado, se o caso, em razão da ausência de Defensoria Pública instalada na Comarca, expeça-se CERTIDÃO DE HONORÁRIOS aos advogados nomeados, nos termos da tabela do convênio existente entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Declaro o perdimento de todos os bens apreendidos com os réus em favor da União, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.

Proceda-se à destruição da droga apreendida, caso remanescente.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Pirajuí, 27 de agosto de 2022.